

1006050-11.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... qualquer conduta ilícita sua. Em razão do furto e da clonagem da linha telefônica, terceiros conseguiram acesso ao dispositivo móvel, não havendo conduta ilícita. Reitera que encaminhou as medidas de segurança possíveis, as quais somente foram adotadas em 16/08/2021. Acrescenta que não há provas de que os terceiros tiveram acesso aos dados de sua conta, já que foi efetivada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo - SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006050-11.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006050-11.2022.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Moisés Esmeraldo Nogueira

Requerido:

CLARO S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO.

É caso de julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, noto que a questão é eminentemente de direito e, no que tange aos fatos, já estão devidamente comprovados nos autos com os documentos que foram juntados pelas partes, as quais dispensaram a produção de outras provas. Não há necessidade de prova oral, já que a documental é a forma adequada e suficiente para a demonstração dos fatos tratados na lide.

Afasto a arguição preliminar concernente à ilegitimidade passiva da corré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., na medida em que essa empresa compõe o mesmo grupo econômico do Whatsapp LLC, possuindo, pois, legitimidade para representá-lo em território nacional.

Rejeito a arguição preliminar tangente à ilegitimidade passiva da corré Claro S/A,

uma vez que é incontroversa a existência de relação com parte autora; a apuração da existência ou não de responsabilidade civil quanto ao evento danoso é questão do mérito.

Não acolho também a arguição preliminar referente à necessidade de realização de exame pericial, pois a narrativa presente em exordial acompanhada dos documentos apresentados é suficiente à demonstração da suposta falha.

Quanto à decadência do direito, não prospera, uma vez que, tratando-se de ação que pretende indenização por defeito na prestação de serviço, aplica-se prazo prescricional de 5 anos, em conformidade para com o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à arguição preliminar de cerceamento de defesa, essa não procede, porque as provas, independentemente de serem produzidas unilateralmente, são legais e serão valoradas tal como postas.

Sobre a necessidade de suspensão do processo até conclusão de investigação criminal, não se faz essencial para a resolução do litígio presente, na medida em que aborda a responsabilidade das corrés quanto à falha na segurança de sua prestação de serviço. Vigora no nosso ordenamento, em regra, a independência das esferas.

Quanto à arguição preliminar remetente à correção do valor atribuído à causa, acolho-a, uma vez que, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve relacionar-se aos pedidos, não tendo sido pleiteado qualquer quantia vinculada aos empréstimos alegados, mas tão somente indenização a título de danos morais. Por conseguinte, possível, nesse momento processual, a correção do valor da causa, de ofício, para que conste R\$20.000,00 – quantum dentro da alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

Finalmente, a questão acerca da exibição de documentos será valorada por meio da distribuição do ônus da prova e pelo momento pelo qual a prova, documental, poderia e deveria ter sido produzida.

Presentes, pois, as condições da ação e os pressupostos processuais.

A parte autora aduz que foi assaltado no dia 13/08/2021 e, em seguida, procedeu para com o bloqueio de sua conta bancária e cartões de crédito, frisando que não forneceu qualquer senha do dispositivo no momento do delito. Registrou boletim de ocorrência, solicitando bloqueio do IMEI de seu aparelho celular. Aponta que, ao acessar seu dia dias posteriores, verificou que cinco empréstimos tinham sido realizados em seu nome por meio da AME Digital – R\$23.500,00, R\$2.300,00, R\$5.000,00, R\$5.000,00 e R\$6.200,00. Informou que esses eram resultado de fraude, enviando-lhe boletim de ocorrência e os e-mails dos empréstimos. Apesar de ter conseguido cancelar 4 de 5 empréstimos, aquele de valor R\$23.500,00 continua a ser cobrado. Afirma que os protocolos abertos solicitando suspensão da linha telefônica, restituição da linha e troca de chip telefônico não foram feitos por ele. Enviou solicitação de bloqueio do aplicativo Whatsapp. Por conseguinte, pleiteia, face à falha na prestação de serviço quanto à proteção de dados, indenização a título de danos morais de R\$20.000,00.

A corrê Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., por sua vez, sustenta que não há defeito na prestação de serviço, pois não se verifica falha na segurança do aplicativo tampouco qualquer conduta ilícita sua. Em razão do furto e da clonagem da linha telefônica, terceiros conseguiram acesso ao dispositivo móvel, não havendo conduta ilícita. Reitera que encaminhou as medidas de segurança possíveis, as quais somente foram adotadas em 16/08/2021. Acrescenta que não há provas de que os terceiros tiveram acesso aos dados de sua conta, já que foi efetivada a desativação assim que solicitado. Destarte, pontua o excludente de responsabilidade por culpa de terceiros e a ausência de comprovação do dano moral, não superando os fatos mero aborrecimento.

A corrê Claro S.A. argumenta que não há comprovação de invasão ao aplicativo, que pode ser operado externamente ao aparelho móvel. Alega que há culpa exclusiva da vítima, por ser possível afirmar que o terceiro já estava na posse dos dados. Para ela, não há danos morais, uma vez que não se vislumbra ofensa a direito personalíssimo ou abalo à ordem subjetiva.

Pois bem.

A relação jurídica instituída entre as partes é regida pela legislação consumerista, visto que a parte autora configura-se, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto consumidora, ao passo que a parte ré, como prevê o art. 3º desse Diploma Legal, manifesta-se enquanto fornecedora de serviços. A responsabilidade pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de serviço é do tipo objetiva, de modo que basta a indicação do nexo de causalidade entre fato e dano, independentemente de culpa, podendo ser afastada mediante prova de que o defeito inexistiu ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor).

É dos autos que a parte autora foi vítima de furto realizado por terceiros, os quais, então, praticaram fraudes.

A parte autora contatou a corré Claro S/A para realização da suspensão da linha telefônica, exclusão do aparelho da lista "cemi", restituição da linha telefônica e troca de chip no dia 14/08/2021 (fls.23/24). Houve solicitação, no dia 16/08/2021, de suspensão e restituição da linha telefônica e troca do chip (fls. 22).

A ocorrência de golpes em que estelionatários conseguem acesso a aplicativos de conversação de terceiros para, então, ludibriar suas vítimas é ordinário. No entanto, esses podem efetivar-se, geralmente, de duas formas distintas: na primeira, o estelionatário colhe os dados da vítima e envia-lhe mensagem solicitando código de verificação do aplicativo Whatsapp, de modo que, após obtenção do código, conseguem acessar o aplicativo e a lista de contatos; na segunda, há clonagem do chip, a qual possibilita ao estelionatário acessar a todos os aplicativos, situação em que a vítima perde, de forma absoluta, seu aparelho celular.

Entretanto, esses dois métodos não se aplicam precisamente ao caso em tela, na medida em que não se trata de clonagem do chip da parte autora, mas, sim, de troca irregular de titularidade de linha, uma vez que ao que tudo indica terceiros apresentaram-se à loja física da corré Claro S/A e solicitaram suspensão da linha telefônica, sua restituição e, posteriormente, a troca de chip. A partir disso, obtiveram acesso a aplicativos.

A corré Claro S/A franqueou ao estelionatário troca da titularidade da linha telefônica a partir de singelo processo de suspensão e restituição da linha telefônica, com alteração do chip, o que permitiu o acesso aos aplicativos e a contratação de empréstimos.

Por mais que a corré Claro S/A não seja responsável pela administração dos aplicativos, a fraude envolvendo-os somente foi possível em decorrência do fato de que o fraudador valeu-se, indevidamente, da troca (irregular) da titularidade da linha telefônica.

A troca irregular de titularidade de linhas telefônica configura riscos que devem ser atribuídos ao fornecedor de serviço pela falta de segurança do sistema, ensejando que terceiros fraudadores cometam crimes como os narrados na exordial. Por conseguinte, evidente a falha na prestação de serviço, a invocada tese de culpa de terceiro não se mostra capaz de afastar a responsabilidade civil da corré Claro S/A, não se aplicando, consequentemente, ao caso em tela, o disposto no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Presente, pois, conduta ilícita da corré Claro S/A.

Quanto aos danos morais, esses caracterizam-se, na medida em que a parte autora logrou comprovar a extensão dos atos dos fraudadores (tais quais a contratação de empréstimos, às fls.42/51), os quais apenas foram possíveis devido à falha na segurança de prestação de serviço da corré Claro S/A. O valor pleiteado, porém, não se justifica, sendo, a despeito da falha constatada, desproporcional. A indenização a título de danos extrapatrimoniais deve apresentar como parâmetros a gravidade e a extensão do dano, a posição socioeconômica das partes e seu papel na ocorrência dos prejuízos reclamados. Ainda, deve fundamentar-se na finalidade reparatória do instituto, sendo suficiente à compensação da vítima sem engendrar seu enriquecimento ilícito.

No caso em tela, em atenção aos parâmetros delineados pela jurisprudência e sopesando a falha verificada, arbitro a compensação em R\$5.000,00 a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto à corrê Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., não se manifesta ato ilícito, posto que, ao ser notificada pela parte autora de que havia sido vítima de furto de aparelho celular, tendo os agentes acessado seu Whatsapp, deu prosseguimento para a desativação da conta, ou seja, a suspensão temporária, conforme documentos acostados pela própria parte autora à fl.61/62. Não se pode inferir que houve falha na segurança da prestação de serviço. Portanto, a pretensão face à ela não procede.

DECIDO.

Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação a pretensão para condenar a corrê Claro S/A a indenizar, a título de danos morais, a quantia de R\$5.000,00, corrigida monetariamente de acordo com os índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desse arbitramento (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça); e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão face à corrê Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Sem custas e honorários nesta fase processual.

As partes poderão recorrer desta sentença no prazo de 10 dias, por meio de advogado, desde que recolham o devido preparo recursal, correspondente à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; e à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório – tudo de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 15.855/2015, que alterou a Lei de Custas nº 11.608/2003 – em guia GARE – código de receita 230-6 –, além de porte de remessa e retorno dos autos (em Guia do Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça), se houver gravação em mídia digital – tudo a ser recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Ademais, nos termos do Comunicado CG 1530/2021, também deverão ser recolhidas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisa de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc.). As guias deverão observar os requisitos do Provimento 33/2013, sob pena de o recurso ser considerado deserto. O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rcl 4.855/PE).

Caso haja eventual pleito de gratuidade, além da declaração de hipossuficiência, a parte que o postular deverá apresentar as duas últimas declarações de bens e rendimentos utilizadas para fins de imposto de renda perante a Receita Federal, ou caso se declare, sob as penas da lei, contribuinte isenta de I.R., deverá anexar os dois últimos comprovantes de rendimentos mensais, no prazo de cinco dias ou junto com eventual recurso interposto, sob pena de indeferimento do benefício postulado. Oportunamente, arquivem-se, anotando-se a extinção junto ao sistema.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA